

1525895-83.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... o requerimento de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art.28 do diploma legal citado, que sequer foi suscitado pela ré, no momento de sua prisão.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

A ré é reincidente em crime de tráfico, consoante certidão de fls. 26, já tendo sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1525895-83.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1525895-83.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SHEILA CORREIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

Sheila Correia, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo apurado, no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 12h, em ocasião de calamidade pública, na Rua Manoel Dutra, 454, Bela Vista, nesta cidade e comarca da capital, vendia e trazia consigo, drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 3.0g (três gramas) de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 06/07 e laudo de constatação a fls. 20/22.

A denúncia foi recebida, a ré foi citada e notificada e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em quem foram ouvidos dois policiais. A ré não foi encontrada no endereço por ela fornecido e assim foi declarada revel e não foi interrogada. (fls. 213/217 e 230)

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público buscou a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa pugnou em sede preliminar a nulidade do feito pelos seguintes motivos: "ilegalidade da busca pessoal, que teria sido feita em dissonância com o previsto

no CPP ", prova ilícita em razão da não realização do "aviso de Miranda" quando da prática da prisão em flagrante"; e consequente absolvição nos termos do art. 386, III do CPP. No mérito, propriamente dito, requereu ainda pela improcedência da ação penal por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Em caso de eventual condenação, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas; ou ainda em caso de condenação por delito de tráfico, fixação da pena em seu piso mínimo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea da ré, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, com fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena e ainda o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição da acusada à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Por primeiro, não há que se falar em falta de comunicação à ré de seu direito de ficar em silêncio.

Isso porque, não há nos autos provas dessa alegação por parte da acusada, que consoante verifica-se de fls.11, " manifesta seu direito Constitucional de permanecer calada nesta fase pré-processual, conforme dispõe o inciso LXIII do artigo 5º da CF".

Ora, o que seria então o "aviso de Miranda" senão os esclarecimentos prestados pela autoridade policial a ré e o respeito ao seu direito de ficar em silêncio?

Por outro lado, apenas para que não seja alegada omissão quanto a tal direito por parte do policiais civis que a prenderam em flagrante, já que se tratou de uma abordagem oral, cabendo a parte alegar e comprovar o fato que pretende ser utilizado para anular a prova, o que sequer foi mencionada pela própria réu na oportunidades em que foi ouvida.

Também não há que se falar busca pessoal ilícita, já que segundo os depoimentos dois policiais ouvidos a ré foi vista em local já conhecido por ser de trafico ilícito de entorpecentes, em atitude típica de venda de drogas e como estavam em campana e assim um pouco longe, a abordaram para confirmar ou não a suspeita.

Mais uma vez, o que seria a fundada suspeita, que autoriza a busca pessoal, e está prevista no parágrafo único, do art. 240, do CPP, senão duas pessoas conversando em um local conhecido pela prática de trafico de drogas, que se realiza comumente a partir de uma aproximação inicial?

Superadas todas as preliminares levantadas pela Defesa, verifica-se que a materialidade do delito restou cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e laudo de constatação dos entorpecentes, pelo laudo pericial com resultado positivo para cocaína, (fls. 138/140), bem como pela prova oral colhida em solo policial e em juízo.

A autoria também é inconteste.

Os dois policiais ouvidos em juízo foram unânimes em afirmar que faziam campana no local dos fatos, já conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes e visualizaram o momento em que um rapaz se aproximou da ré em atitude típica de ato de compra de entorpecentes e assim resolveram aborda-los.

Durante a abordagem com a ré foi encontrada uma pequena quantidade de drogas e uma quantia em dinheiro. Com o rapaz nada de ilícito foi encontrado e em razão disso ambos foram encaminhados à delegacia de Policia onde foi lavrado o boletim de ocorrência.

A versão dos policiais, ao contrário do alegado pela Defesa foi corroborada pelo depoimento de Milton Leonardo Romera Mansilha, que ao ser ouvido pela autoridade policial, confirmou que se aproximou da ré para dela comprar entorpecentes e que no momento em que ambos conversavam foram abordados por policiais. Milton disse ainda que: conhece a indiciada Sheila do próprio bairro onde residem e, ratifica, ser apenas usuário de drogas, contudo sabe dizer que ela tem por hábito comercializar entorpecentes. O depoente foi então conduzido pelos Policiais Civis a esta Unidade Policial juntamente com Sheila". (fls. 05).

Ora, o fato de seu depoimento não ter sido ratificado em juízo, não tem o condão de simplesmente fazê-lo desaparecer dos autos, como quis fazer crer a Defesa. Isso porque, a versão da testemunha foi devidamente corroborada pelos depoimentos dos policiais em juízo que confirmaram a apreensão da ré e de um usuário que com ele conversava.

Deve-se deixar claro, ainda, que as declarações prestadas na fase administrativa, nos termos do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório.

A ré, por sua vez, não foi localizada no endereço por ela mesmo mencionado quando de sua soltura e assim não foi ouvida em juízo.

Portanto, essas são as provas colhidas nos autos e diante delas, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, não há que se falar em absolvição da acusada.

Cabe ainda, aqui destacar que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais e agentes públicos aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos, indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais civis contra o acusada.

Nesse sentido:

“Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Por fim, pondera-se que a ré foi presa no momento em que vendia drogas a terceira pessoa, neste ponto afasta-se por completo o requerimento de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art.28 do diploma legal citado, que sequer foi suscitado pela ré, no momento de sua prisão.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

A ré é reincidente em crime de tráfico, consoante certidão de fls. 26, já tendo sido condenada definitivamente nos autos nº 0050878-46.2018.8.26.0050, fato este que será devidamente considerado na segunda fase de aplicação de pena.

Por outro lado, não tem outros antecedentes criminais e assim sendo lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código de Processo Penal e, portanto, a pena base será mantida no mínimo legal estabelecido de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, deve-se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que ainda assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Ainda mais na época dos fatos em que estávamos frente a uma doença que parecia ser invencível, e que estava causando milhares de mortes por todo mundo.

Neste ponto respeitadas as posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020- "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais

foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP -Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 -Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020).

Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

9ª Câmara Criminal- Des. Fátima Gomes: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.

Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo

para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se. Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la.

Também há que se considerar a reincidência específica da ré. Assim sendo, a pena-base deve ser agravada em 1/5 chegando-se a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Por outro lado, não há que se falar em reconhecimento da confissão, já que a ré manifestou seu desejo de ficar em silêncio na fase policial, única oportunidade em que foi encontrada para ser ouvida.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, se mostra incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente em razão de sua reincidência específica.

Neste ponto, não há que se falar na ocorrência de bis in idem ao se considerar a reincidência para agravar a pena e, ao depois, negar a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, conforme já decidido, "...na aplicação do preceito em foco, o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena, não se podendo falar em bis in idem por ter sido a reincidência considerada para aumentar as sanções e também impedir a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois a aplicação de tal dispositivo exige a ocorrência simultânea de todas as condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado.

Conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, "não há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente" (HC 118403/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009)." (Apel. Crim. Nº 990.10.184009-0, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro).

Outrossim, "O agravamento da pena pela reincidência também está correto e decorre de expressa determinação legal. Não ocorreu bis in idem. Não é raro que uma mesma circunstância reflita em mais de uma direção. O reincidente, v.g., não tem direito a sursis, por expressa disposição legal. Não obstante, o magistrado é obrigado a exacerbar sua pena, porque a reincidência também é agravante. Seguindo o mesmo raciocínio, no caso ora em exame, não aplicável a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a recidiva, a qual também é usada para agravar a pena, por determinação legal." (Rev.

Crim. NCrim. Nº 990.09.160794-0, 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Eduardo Pereira).

No mesmo sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. MINORANTE

AFASTADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 3. Ausência de bis in idem na condenação que aplica a agravante de reincidência e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por ausência de atendimento aos requisitos para a aplicação da privilegiadora. 4. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 191.580 2ª Turma do STF Rel. Min. Edson Fachin j. 16/11/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. MINORANTE DO § 4º NÃO APLICADA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não configura bis in idem. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 558867/SP 5ª Turma do STJ Rel. Min. Joel Ilan Parcicionik j. 02/2/2021).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar a ré como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, fixados no mínimo legal, já que não há nos autos provas da condição econômica da acusada.

Por fim, considerando sua reincidência e ainda o disposto no art. 2º da Lei de Crimes Hediondos, o regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado, pois se ajusta e convém a acusada pela manifesta periculosidade e insolente menoscabo das regras que disciplinam o convívio social, já que solta, novamente foi presa pela prática do mesmo crime.

Apenas a título de argumentação, não há que se falar em pequena quantidade de droga apreendida para a fixação de regime mais benéfico, isso porque, como é notório e amplamente divulgado em todos os meios de comunicação, cada vez mais as pessoas são presas traficando na posse de pequenas porções de drogas, notadamente para se garantir que o tráfico perca o menos possível no momento em que ocorrem as prisões. Apesar de todo o exposto, considerando que a ré foi solta por este processo em razão de decisão da Corte Superior e não havendo pedido expresso ou mesmo novos motivos que levem a decretar sua prisão cautelar, poderá recorrer desta em liberdade.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de execução definitiva e oficiem-se TRE e IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Com a juntada aos autos, abra-se vista às partes para ciência e eventual manifestação.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA